

1502854-63.2021.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... sentido, diversos julgados do E. TJSP:

"Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Condenação. Cabível - Nulidade da apreensão realizada por guarda municipal - Não acolhida - Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Lei 13.022/14 - Aos guardas-civis, na qualidade de agentes públicos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502854-63.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Inquérito Policial - 3065474/2021 - 05º D.P. PIRACICABA, 19516631 - 05º D.P. PIRACICABA, 2214381/2021 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODINEI SANTARATO

Contr. nº 2021/001030

Aos 05 de outubro de 2022, às 16:20 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva, foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Ausente o réu RODINEI SANTARATO, o qual foi devidamente intimado do presente ato (fls. 153) e se encontra egresso.

Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Rafael Alvarez Moreno.

Presente(s) a(s) testemunha(s) comum: GC Nilton Francisco Barbosa e GC Raphael Monteiro Júnior.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, diante da ausência do réu, que se encontra egresso e foi devidamente intimado para comparecer ao presente ato (fls. 153), pela MM. Juíza foi dito que decretava a sua REVELIA.

Na sequência, pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, através de exibição à câmera de documento original com foto, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GC NILTON) foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa, por eles foi dito que desistiam da oitiva da testemunha GC RAPHAEL, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). RODINEI SANTARATO, está sendo processado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 09 de agosto de 2021, às 10h15, na Rua Lisboa, s/nº, bairro Vila Sônia, nesta Cidade e Comarca de Piracicaba trazia consigo para consumo pessoal, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L., erva vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 2,3 g (dois gramas e três decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 48/54, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (fls. 71/72). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 04/05, foto a fl. 45/47 e laudo pericial a fls. 118/120. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o guarda Nilton relatou, na fase informativa (fls. 07), que "NA DATA DE HOJE, JUNTAMENTE COM MEU COLEGA DE SERVIÇO NILTON, FAZÍAMOS POLICIAMENTO PELO BAIRRO PQ. ORLANDO, QUANDO PRÓXIMO A RUA LISBOA COM A RUA MADRI, ONDE EXISTE UMA ÁREA VERDE, AVISTAMOS CINCO INDIVÍDUOS EM ATITUDES SUSPEITAS, SENDO ASSIM RESOLVEMOS ABORDÁ-LOS, CONTUDO, OS MESMOS AO PERCEBEREM A NOSSA APROXIMAÇÃO EMPREENDERAM FUGA, EXCETO UM DELES, O QUAL FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO RODINEI SANTARATO E TAMBÉM LOGAMOS ÊXITO EM ABORDAR LOGO EM SEGUIDA A PESSOA DE HENRIQUE BUENO MOREIRA, O QUAL FAZIA PARTE DAQUELE GRUPO DE PESSOAS; QUE EM PODER DE RODINEI FORAM ENCONTRADAS DUAS PORÇÕES DE MACONHA E EM PODER DE HENRIQUE FORAM ENCONTRADAS 28 PORÇÕES DE MACONHA IDÊNTICAS AS QUE FORAM ENCONTRADAS COM RODINEI, ALÉM DE 20 PORÇÕES DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R\$ 69,00; QUE AMBOS FORAM INDAGADOS E RODINEI AFIRMOU QUE HAVIA ACABADO DE COMPRAR AS DUAS PORÇÕES DE MACONHA DE HENRIQUE E ESTE, POR SUA VEZ, CONFIRMOU QUE ESTAVA NO LOCAL VENDENDO DROGAS; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO À HENRIQUE, CONTUDO, APESAR DO MESMO NÃO TER REAGIDO, ANTES DE SER ABORDADO QUANDO TENTOU FUGIR ACABOU CAINDO E SOFRE UMA PEQUENA ESCORIAÇÃO NO JOELHO". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que o réu estava com outras 5, 6 pessoas usando drogas. Alguns conseguiram se evadir. O réu informou que tinha comprado drogas de pessoa de nome Henrique. Ele estava na posse de 2 invólucros de maconha. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu é multirreincidente e ostenta maus antecedentes (certidões a fls. 154/158).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foram apresentadas alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

RODINEI SANTARATO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de agosto de 2021, às 10h15, na Rua Lisboa, s/nº, bairro Vila Sônia, nesta Cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo para consumo pessoal, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L., erva vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 2,3 g (dois gramas e três decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 48/54, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina, momento em que avistaram cinco homens em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura,

empreenderam fuga, exceto Rodinei e outro rapaz. Ato contínuo, os milicianos procederam à abordagem e em revista pessoal foram encontradas 02 (duas) porções de "maconha" em posse do acusado, o qual, após indagado, disse que havia comprado a droga para consumo pessoal.

O réu foi notificado às fls. 107. Defesa preliminar apresentada às fls. 98/101. Após, a denúncia foi recebida aos 11/05/2022 (fls. 115/116) e o réu foi citado (fls. 127).

Durante a audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum. O réu não foi interrogado, pois revel.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com a condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime.

A Defesa pleiteou a absolvição, arguindo ilicitude da ação dos guardas e, no mérito, alegando insuficiência probatória e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilicitude na ação dos guardas civis e, consequentemente, nulidade da prova.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação suspeita, ao lado de algumas pessoas, todas aparentando portar drogas e fazendo uso delas. Ao notarem a aproximação da viatura, elas tentaram se esquivar, deixando rapidamente o local, o que estavam praticando um ilícito penal e permitiu a atuação dos guardas civis.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Neste sentido, diversos julgados do E. TJSP:

"Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Condenação. Cabível - Nulidade da apreensão realizada por guarda municipal - Não acolhida - Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Lei 13.022/14 - Aos guardas-civis, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo flagrado a ré em conduta clara e suspeita, em local conhecido pela prática do narcotráfico, sendo certo que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Desnecessidade de critérios rígidos para realização de busca pessoal. A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que a apelada foi abordada e presa em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos agentes da lei harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada. Os guardas municipais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. Negativa da ré restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar a ré da condenação. Prova da finalidade de entrega a terceiros advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal. Aplicada a causa de redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos - Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial

semiaberto. Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da autora. Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal 1519489-12.2021.8.26.0228. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 24/08/2022) - g.n.

"PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PATRULHAMENTO ROTINEIRO - AVISTAMENTO DE VEÍCULO DENUNCIADO PELA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS MINUTOS ANTES - ABORDAGEM QUE SE FAZIA OBRIGATÓRIA - HIPÓTESE DE FLAGRANTE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA OU INVESTIGATIVA - LEGITIMIDADE DE QUALQUER DO POVO REALIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - ART. 301, DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP - Apelação Criminal 1500202-11.2021.8.26.0601. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Jayme Walmer de Freitas - j. 22/08/2022) - g.n.

"Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Sentença condenatória - Preliminares de nulidade em face: (i) do indeferimento de realização de incidente de dependência toxicológica; (ii) da alegada ilicitude da prova colhida mediante suposta invasão de domicílio; e (iii) da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Rejeição - Dúvida sobre a higidez mental ou dependência química do acusado, ao tempo dos fatos, não demonstrada - Decisão que indeferiu a diligência com manifestação suficiente - Hipótese de crime permanente - Situação de flagrância que se protraí no tempo - Não há que se cogitar de prova ilícita por violação de domicílio, máxime para efetuar prisão em flagrante - Busca e apreensão realizada por guardas municipais, realizadas de forma regular - No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a concessão do privilégio contido no artigo 33, parágrafo 4º, da lei antedita, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional - Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de guardas municipais importantes na elucidação dos fatos - Condenação acertada, diante de acervo probatório robusto e convincente - Penas-base reduzidas - Afastada causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Grande quantidade de droga a ser considerada, somente, na terceira etapa da dosimetria, inclusive para justificar o afastamento da causa de diminuição - Privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, não compatível com o contexto dos autos - Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Repercussão concreta da conduta do agente - Regime prisional fechado mantido. Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal 1501017-81.2019.8.26.0567. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi - j. 23/08/2022) - g.n.

"Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão feita pelos Guardas Municipais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, afastamento da agravante da calamidade pública, reconhecimento da menoridade, e aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando. Preliminar afastada - Ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais. Inocorrência - Crime de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. Ademais, qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em flagrante (art. 301, do CPP). Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Apreensão de 12 porções de cocaína na forma de crack (peso líquido 439,9 gramas). Guardas Municipais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas. Condenação que se impõe. Dosimetria - Pena-base

justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, afastamento da circunstância agravante da pandemia, e compensação entre a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência. Não cabimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 por falta de amparo legal. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo parcialmente provido, para afastar a agravante da pandemia e reduzir a pena nos termos deste voto" (TJSP - Apelação Criminal 1522530-84.2021.8.26.0228. 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ely Amioka - j. 24/08/2022) - g.n.

"APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória, que reconheceu a nulidade da abordagem do réu por guardas civis - Irresignação ministerial - Inocorrência de ilegalidade - Abordagem pessoal do réu realizada pelos guardas civis municipais motivada por fundada suspeita - Legitimidade e constitucionalidade da conduta dos guardas civis à luz do disposto no artigo 144, § 8º, da CF - Inteligência do art. 301, CPP - Mérito - Pedido de condenação do réu nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Possibilidade - Materialidade do delito comprovada pela apreensão das substâncias e alta quantia em dinheiro e constatação da presença dos respectivos princípios ativos atestada por laudo químico toxicológico - Testemunho harmônico e coerente dos guardas municipais com os demais elementos colhidos na fase policial e instrução criminal que desmentem a negativa de autoria do réu - Condenação do réu, que é de rigor - Dosimetria - Primeira fase - Pena fixada no mínimo legal - Natureza e quantidade de drogas que não transbordam o tipo - Segunda fase - Reincidência que deve ensejar aumento de 1/6 - Terceira fase - Não incidência da causa da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante ao não preenchimento dos requisitos legais - Apelante reincidente - Regime fechado fixado como inicial cumprimento de pena - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena afastadas. Apelação parcialmente provida, para julgar procedente a ação penal e condenar o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 (TJSP - Apelação Criminal 1502274-06.2020.8.26.0536. Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Renato Genzani Filho - j. 19/08/2022) - g.n.

O C. STF também se manifestou recentemente no mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (STF - HC 212635 - AgR. - Primeira Turma - Relator(a): CÁRMEN LÚCIA - j. 11/04/2022).

No mérito, a denúncia procede.

Autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 01/03, auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, fotografia de fls. 47, pelo auto de constatação (fls. 49/54) e laudo toxicológico de fls. 118/120, ambos com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) em relação à substância apreendida, bem assim pela prova oral, a seguir analisada.

Vejamos:

Ouvido na fase extrajudicial (fls. 09), o réu confessou que, no dia dos fatos, estava na área verde e possuía duas porções de maconha, as quais havia comprado de Henrique, pagando R\$ 5,00 por cada uma. Admitiu que, quando os guardas o abordaram, estava com a droga em seu poder. Esclareceu que foi a primeira vez que comprou droga de Henrique.

Em juízo, não exerceu a autodefesa, tornando-se revel.

A confissão do réu foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 07) e sob o crivo do contraditório (gravação), o guarda civil Raphael Monteiro Junior declarou que, no dia dos fatos, faziam patrulhamento de rotina quando, numa área verde do bairro Pq. Orlando,

avistaram um grupo de cinco indivíduos que aparentavam usar entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, quatro deles se dispersaram empreendendo fuga e um permaneceu no local, no caso, o acusado Rodinei. Relatou que abordaram o acusado e outro indivíduo, o Henrique, que havia se evadido do local, mas que conseguiram alcançar. Na revista pessoal, encontraram com o acusado duas porções de maconha. Henrique possuía em dinheiro, 20 porções de cocaína e 28 porções de maconha, essas idênticas às de Rodinei. Indagado, o réu confessou que havia acabado de comprar aquelas duas porções de maconha de Henrique, e este, por sua vez, admitiu que estava no local vendendo drogas.

No mesmo sentido as declarações prestadas na fase informativa pelo guarda civil Nilton Francisco Barbosa (fls. 08).

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Neste sentido tem reiteradamente se manifestado a jurisprudência: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo, para uso pessoal, 02 (duas) porções de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

De rigor, pois, sua condenação pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em que pese a manifestação da nobre defesa, não há inconstitucionalidade no referido dispositivo legal, porquanto, ao contrário do alegado, inexiste ofensa ao princípio da lesividade, eis que o porte de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, é conduta que atenta contra a saúde pública e outros bens jurídicos.

De fato, apesar de o usuário da droga prejudicar diretamente a própria saúde, não se pode olvidar que a coletividade, como um todo, também é colocada em risco, porquanto o vício das drogas tem o potencial de desestabilizar o sistema vigente. Neste sentido tem reiteradamente se manifestado a jurisprudência.

Confiram-se julgados recentes do E. TJSP:

"Art. 28, da Lei n. 11.343/2006 - Materialidade e autoria comprovadas por robusto conjunto probatório - Crime permanente - Situação de flagrante que se protraí no tempo e admite o ingresso no domicílio alheio sem prévio mandado judicial e autorização do morador - Prova ilícita não configurada - Inconstitucionalidade da norma penal não verificada - Princípio da insignificância - Impossibilidade de aplicação - Crime de perigo presumido ou abstrato - Réu reincidente - Pena de advertência incabível - Reprimenda imposta (prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses) que atende ao disposto no § 4º do art. 28, da Lei n. 11.343/2006 - Recurso desprovido - Sentença mantida" (TJSP - Apelação Criminal 1505902-60.2020.8.26.0032; Relator (a): Leonardo Lopes Sardinha; Órgão Julgador: Turma Criminal - j. 04/10/2022).

"PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por falta de provas em relação aos crimes de ameaça e vias de fato e por inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena de multa para a contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça; o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal; do crime continuado, quanto às ameaças e, por fim, da prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do período de prova do sursis. Parcial cabimento. 1. A) Absolvição em relação aos crimes de ameaça e vias de fato. Impossibilidade. O fato e a autoria

restaram cabalmente demonstrados pelos relatos concisos da vítima e das testemunhas policiais, ficando constatado que as ameaças proferidas pelo réu causaram temor na ofendida, sendo o que basta para o reconhecimento do delito de ameaça, que é formal e instantâneo, além disso, bem como comprovada a contravenção pela prova oral. Condenação mantida. B) Absolvição. Impossibilidade. Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso. Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. 2. Dosimetria. A) Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal. Inviabilidade. Na espécie, a infração imputada ao acusado (artigo 147 do CP), por sua natureza, poderia ser praticada fora do contexto de prática do crime prevalecendo-se o agente das relações domésticas. Por isso não traduz na sua constituição fundamental a proporcional sanção quando decorrente da violência doméstica, pelo que adequada a incidência do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Do mesmo modo correta a aplicação da referida agravante ao artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. B) aplicação somente de multa. Impertinência. Expressamente vedadas pelo artigo 44, inciso I do, Código Penal e artigo 17 da Lei nº 11340/06, inaplicáveis a substituição penal e a cominação de multa isolada. C) Afastamento do crime continuado em relação aos crimes de ameaça. Impossibilidade. Correto o reconhecimento do crime continuado, em relação às ameaças, porque praticadas duas ameaças, mas em condições semelhantes de tempo, lugar e em modo de execução. 3. Afastamento da aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade. Possibilidade. Reparo em condição de sursis, com afastamento da prestação de serviços à comunidade (por ser a pena corporal não superior a 6 meses - art. 46 CP), e sua substituição por limitação de fim de semana. Parcial provimento" (TJSP - Apelação Criminal 1500161-28.2021.8.26.0574; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/09/2022).

Por outro lado, a pequena quantidade também não impõe a aplicação do princípio da insignificância ou do crime de bagatela, pois o texto legal não faz limitação de ordem quantitativa do objeto material.

Dessa forma, não importa para a caracterização do tipo penal em questão a quantidade de substância apreendida, como reiteradamente vem decidindo nossos tribunais, pois a tipicidade está vinculada às propriedades da droga, ao risco social e a saúde pública, e não à lesividade comprovada em cada caso concreto. Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é duplamente reincidente (condenações definitivas por furto qualificado nos processos nº 0001594-35.2015.8.26.0451, da 2ª V.C. local, cuja pena isolada de multa foi paga na data de 13/10/2016 - fls. 154; e nº 0005501-18.2015.8.26.0451, também da 2ª V.C. local, com trânsito aos 20/10/2017, e pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 23/07/2021 (fls. 154/155).

Por outro lado, o réu tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria do crime. Não há outras circunstâncias modificadoras das penas.

Diante desse contexto, considerando a reincidência e, por outro lado, a atenuante, aplico a medida de cinco meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu RODINEI SANTARATO à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, por incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Diante disso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO para a acusação, nesta data.

Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário.

Intime-se o(a) ré(u) do teor da sentença, bem como se dela deseja recorrer. Com a juntada do mandado, devidamente cumprido, dê-se vista à Defensoria Pública para eventual interposição de recurso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, ASSF, assistente judiciário, digitei.